



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000111589

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002745-94.2016.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante ALESSANDRO SERGIO DE MELO YOSHINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 14^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para redimensionar a reprimenda de Alessandro Sérgio de Melo Yoshino para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, mantendo no mais a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE LORENZI (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E HERMANN HERSCHANDER.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.

MARCO DE LORENZI
RELATOR

Assinatura Eletrônica

(art. 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Voto: 24269
Apelação: 0002745-94.2016.8.26.0097
Comarca: Buritama
Vara: 1ª Vara
Processo: Numeração única
Apelante: Alessandro Sérgio de Melo Yoshino
Apelado: Ministério Público

Vistos...

Ao relatório da respeitável sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Alessandro Sérgio de Melo Yoshino foi condenado, por incurso no artigo 129, § 9º, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f” e “h”, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto; concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos (fls. 170/174; 199).

Apela Alessandro. Preliminarmente, pugna pela nulidade do julgado. Sustenta que foi dada parcial procedência ao pleito acusatório, seguindo-se a interposição de embargos declaratórios, caso em houve modificação do julgado para total procedência, em manifesta *reformatio in pejus*, já que o caso não era de erro material que pudesse ser revisto de ofício. No mérito, postula a absolvição, sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

a fixação do regime aberto, sem a aplicação da suspensão condicional da execução da pena (fls. 230/238).

O recurso foi devidamente contrariado (fls. 247/251; 252/257), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo parcial provimento do apelo defensivo, para afastamento do sursis (fls. 267/275).

É o relatório.

A preliminar não vinga.

In casu, Alessandro foi denunciado por duas agressões em ambiente familiar contra sua genitora, na forma do artigo 71 do Código Penal. Em sede de alegações finais, postulou a promotoria que Alessandro fosse condenado apenas pela segunda agressão (fls. 159/161). Sobreveio a sentença de parcial procedência, dando Alessandro como incurso no artigo 129, § 9º, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f” e “h”, todos do Código Penal, quanto à segunda agressão (fls. 170/174). Seguidamente, houve interposição de embargos de declaração (fls. 194/195), cuja decisão, embora tenha alterado a parte dispositiva de “parcial” para “total” procedência, nada modificou quanto à capitulação e a pena estabelecida, vale dizer, nada se alterou quanto à condenação em relação à segunda agressão (fls. 199), não havendo que falar em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

reformatio in pejus.

De acordo com os doutrinadores Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes, o princípio do prejuízo constitui a viga mestra do sistema das nulidades em nosso processo penal “*e decorre da ideia geral de que as formas processuais representam tão somente um instrumento para a correta aplicação do direito; sendo assim, a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício (...) Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional*” (in “As Nulidades no Processo Penal”, Ed. Revista dos Tribunais, 12ª edição, 2011, p. 27), daí a expressão: *pas de nullité sans grief*.

Ainda nas palavras dos ilustres autores:
 “A decretação da nulidade implica perda da atividade processual já realizada, transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a simples possibilidade de prejuízo dê lugar à aplicação da sanção; o dano deve ser



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

concreto e efetivamente demonstrado em cada situação” (in “As Nulidades no Processo Penal”, Ed. Revista dos Tribunais, 12ª edição, 2011, p. 28).

Destarte, não se verifica prejuízo ao apelante, não havendo que se falar em nulidade da r. sentença.

No mérito.

A acusação acolhida é a de que Alessandro, sob o contexto de violência doméstica e familiar contar a mulher, dolosamente ofendeu a integridade de sua genitora *Irenice Ferreira*, maior de 60 anos de idade e deficiente visual, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Consta que *Irenice* chamou Alessandro para verificar por qual razão o cachorro latia, ocasião na qual o acusado, irritado, após xingá-la, foi até o portão e, ao perceber que não havia ninguém, nela urinou. *Irenice* tentou afastar Alessandro, mas ele segurou o braço da idosa e o arranhou, levantando um pedaço da pele. Na manhã seguinte, a ofendida acionou o setor de assistência social do município e pediu ajuda. As assistentes sociais, então, acionaram a polícia.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5), boletim de ocorrência (fls. 15/18), laudo de lesão corporal (fls. 75).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

A autoria, de igual modo, é inconteste.

Sob o crivo do contraditório, Alessandro rechaçou a imputação. Acerca das lesões no braço da vítima, não soube dizer como foram produzidas (mídia).

A negativa de autoria restou mitigada pelo conjunto probatório.

Em juízo, *Irenice* afirmou que sua cachorra estava latindo nos fundos da casa e por isso chamou Alessandro para verificar. O acusado, com raiva, saiu do quarto e disse que não iria ver o que acontecia, terminando por urinar na pena de *Irenice* bem como arranhar seu braço (mídia).

A testemunha *Andréia Wedekin Chaves*, assistente social, asseverou que não presenciou as agressões e que foi acionada por *Irenice*. Visitada em sua residência, a ofendida relatou que foi arranhada pelo filho e que dele tinha medo (mídia).

A testemunha *Karini Flores Alfredo*, assistente social, corroborou o testemunho de *Andréia*, mormente quanto ao relato de *Irenice* acerca da agressão sofrida (mídia).

A testemunha *Rogério Antony Oliveira*,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

policia militar, declarou que foi acionado por uma assistente social, que contatou a polícia dando conta da violência. No local dos fatos, Irenice narrou que era maltratada pelo filho. *Rogério* não se recordou se a ofendida apresentava algum ferimento (mídia).

A testemunha Lucélia Nobre de Melo, prima de Alessandro, não presenciou os fatos e nada acrescentou para o deslinde do caso (mídia).

A testemunha *Wilson de Souza Nobre*, primo de Alessandro, não presenciou os fatos e nada acrescentou para o deslinde do caso (mídia).

Pois bem.

Em que pese a negativa de autoria, a prova testemunhal se afina com a assertiva acusatória, materializada no laudo de lesões corporais, cujas observações clínicas condizem com a agressão alegadamente sofrida, vejamos o que constou: "*Duas escoriações recobertas por crostas hemáticas, em formato de semi círculo localizadas na face posterior do terço inferior do antebraço esquerdo*" (fls. 75).

Vale nota que, nos casos envolvendo crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime se respaldada em outros informes



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

probatórios, como é a hipótese dos autos.

Neste contexto fático, de rigor a condenação.

A dosimetria foi assim estabelecida.

A pena-base foi fixada no mínimo legal e agravada em 1/3, considerando que a agressão foi perpetrada no âmbito doméstico e contra pessoa idosa (artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal), tornando-se, assim, definitiva (4 meses de detenção); suspensão condicionalmente a pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

A reprimenda merece pequeno reparo.

Há *bis in idem* em relação à condenação do réu como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, e a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, e alínea “f”, do mesmo diploma, pois a circunstância da violência doméstica já se encontra descrita no tipo penal.

Remanesce, entretanto, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (vítima maior de 60 anos de idade – fls. 15), sendo suficiente o incremento de 1/6 na reprimenda.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Com efeito, redimensiono a pena de Alessandro para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

A fixação do regime prisional aberto não comporta reparo.

A violência impede a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos.

Correta, também, a fixação do regime prisional aberto, bem como o *sursis* aplicado.

Ressalte-se que a suspensão condicional da pena foi concedida ao réu e impede a aplicação de pena corporal, ou seja, privativa de liberdade. Portanto, trata-se de um benefício, cuja aceitação não é obrigatória ao réu.

Poderá ele, em sede de execução penal, manifestar a sua renúncia quando da realização da audiência admonitória, pleiteando o cumprimento da pena privativa de liberdade, tal como fixada e em regime aberto, sem aplicação da suspensão condicional da pena.

Nesse sentido:

“Sursis constitui favor, não sendo obrigatória sua



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

*aceitação, podendo ainda ser renunciado, mesmo após
 entrado em vigor, desde que se disponha o réu a
 descontar a penalidade sofrida (...)” (TACRIM – RT
 448/395).*

Ante o exposto, DOU PARCIAL
 PROVIMENTO ao recurso defensivo, para redimensionar a reprimenda
 de Alessandro Sérgio de Melo Yoshino para 3 (três) meses e 15 (quinze)
 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena
 pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, mantendo no mais a respeitável
 sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MARCO DE LORENZI

RELATOR

Assinatura Eletrônica

(art. 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006)